

1500384-81.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Por ele já ter passagem por tráfico. A denúncia falava que, além do ADRIANO, havia mais dois indivíduos na casa, que estavam embalando entorpecentes. Foi isso que levou a gente até a residência. Chegando lá, só encontramos o ADRIANO. Como ele já é conhecido nos meios policiais por tráfico - inclusive a gente até tinha prendido ele anteriormente por tráfico -, foi o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500384-81.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-81.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO MARTINS NEVES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ADRIANO MARTINS NEVES, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 29/03/2022, por volta das 10h00min, na Rua Enio Ferrari, 234, Lençóis Paulista, policiais civis que faziam ronda pela localidade teriam avistado o portão da casa do réu aberto e observado que ele estava a promover o fracionamento de maconha com o auxílio de um estilete e um rolo de fita, o que os motivou a autuá-lo em flagrante delito, já que em sua posse havia três porções brutas da referida droga, pesando 1,310 kg. Requereu, assim, que o réu fosse incurso no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a respectiva condenação.

A denúncia, de fls. 136/138, está acompanhada do auto de prisão em flagrante e documentos de fls. 01/132, de que consta que, na audiência de custódia, foi determinada a segregação cautelar do réu (fls. 79/81) e mantida por este juízo às fls. 119/120 após provocação da Defesa (fls. 98/111).

Notificado, o réu, mediante defensor nomeado, apresentou defesa preliminar às fls. 171/179, acompanhada do documento de fl. 180, aduzindo que a maconha encontrada em sua posse nada mais seria do que folhas, flores e plantas, inexistindo a porção

bruta pronta para o consumo ("tijolos"), de modo que estaria caracterizada a disposição para uso pessoal. Sustentaram terem os policiais invadido sua casa sem mandado de busca e apreensão e que o portão estava fechado. Aduziu que a invasão dos policiais estaria embasada em denúncia anônima, tornando nula qualquer prova coletada, ainda que o portão estivesse aberto. Reiterou o pedido de liberdade provisória.

As fls. 187/189, a denúncia foi recebida, sendo rejeitado novamente o pedido de liberdade provisória, com a designação de audiência de instrução para o dia 03/08/2022.

De ofício, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em 23/06/2022 foi revisitada a necessidade da prisão preventiva, ficando mantida (fls. 218/219).

Na audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela Acusação e uma pela Defesa e o interrogatório do réu. Após, foi determinado o encerramento da instrução, oportunizando-se às partes a apresentação de razões finais escritas (fls. 230/233).

O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 241/250, ratificando os termos da denúncia, pugnando pela decretação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu, com exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de maus antecedentes e pela conduta social mal avaliada; e na segunda fase, pela reincidência específica, sem possibilidade do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 254/260, reiterando a nulidade probatória decorrente da invasão do domicílio do réu sem mandado e sem qualquer situação que justificasse tal ação policial. No mais, afirmou que a droga encontrada seria para consumo próprio, pugnando, dessa forma, pela absolvição ou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de acolhimento da preliminar e declarar a nulidade da apreensão da droga realizada, com a consequente absolvição do réu, tendo em vista a patente ilegalidade da invasão domiciliar perpetrada pelos agentes policiais.

Conforme consta da inicial, policiais civis estariam em ronda em local próximo à casa do réu, quando, então, teriam observado o portão aberto e, no interior do imóvel, o réu fracionando a maconha que seria apreendida, com a decretação de sua prisão em flagrante. Interessante mencionar que a peça menciona que a Polícia Civil já tinha conhecimento do suposto comércio espúrio promovido pelo réu, o que sugere que os agentes estavam lá em decorrência das já conhecidas notícias-crimes anônimas.

Ouvidos em juízo, os policiais civis afirmaram aproximadamente o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

PC JOSÉ AUGUSTO FIDÊNCIO OLLER: No dia dos fatos, recebemos uma denúncia anônima de que o ADRIANO e mais duas pessoas estavam embalando entorpecentes na casa dele. Como o ADRIANO já era conhecido no meio policial, até por tráfico de drogas, resolvemos fazer uma diligência até a residência. Inclusive na denúncia citava até o local que era a casa do ADRIANO. Chegando lá, o portão encontrava-se aberto, e já conseguimos visualizar o ADRIANO no quarto. Um cheiro muito forte de droga vindo do local. Nós vimos o ADRIANO, entramos no quarto, e já de início vimos um pé grande de maconha em cima da cama. Um fato que chamou a atenção dos policiais é que havia folhas da maconha embaladas. Não é uma coisa normal de localizar. Elas estavam embaladas se não me engano em papel filme, tipo para venda. Apesar de serem duas folhas, elas estavam bem semelhantes, pela forma de estarem embaladas, tamanho, e enroladas em papel filme, e isso nos chamou a atenção. Próximo de onde foram localizadas essas folhas de maconha embaladas, encontramos um estilete e um rolo de fita. O que o ADRIANO alegou no momento para nós é que achou aquela droga perto de um rio e que era para uso próprio. Não me recordo se o rolo que encontramos dava impressão de que foi utilizado. Não consigo me lembrar se o rolo estava intacto. As folhas estavam tipo em papel filme, daqueles que quando passamos o rolo e formamos

tipo uma embalagem, papel filme, aquele transparente. A demanda para irmos à residência do ADRIANO. Foi a denúncia que recebemos. Por ele já ter passagem por tráfico. A denúncia falava que, além do ADRIANO, havia mais dois indivíduos na casa, que estavam embalando entorpecentes. Foi isso que levou a gente até a residência. Chegando lá, só encontramos o ADRIANO. Como ele já é conhecido nos meios policiais por tráfico – inclusive a gente até tinha prendido ele anteriormente por tráfico –, foi o que fez nos deslocar até a residência do Adriano. O portão da residência estava aberto. Na hora em que abrimos o portão e já visualizamos o Adriano no quarto, já se sentia o cheiro de droga no portão, fora da casa. Até antes de entrar já dava para sentir esse cheiro da droga. A distância do portão para o quarto é curta: o portão aberto já é de frente para o quarto do ADRIANO, é curta a distância. Não é uma casa que tem fundo, nada disso. [destaques meus]

PC SANDRO DE ALMEIDA SALLES: Nessa data, estávamos na delegacia e recebemos uma denúncia anônima de que o ADRIANO estaria embalando drogas, com outros indivíduos. Como o ADRIANO já é conhecido nosso por envolvimento com o tráfico, e outras ocorrências, fomos até o local, na casa dele. O portão da residência estava aberto. Entramos e surpreendemos o ADRIANO no quarto. Estava um cheiro forte de maconha. Estava o Adriano sozinho no quarto. Não havia mais ninguém na residência, e lá tinha um pé de maconha, duas porções grandes de folhas de maconha embaladas, prontas para venda, e na cama havia um estilete e uma fita adesiva. [destaque meu] Em seguida, colheu-se o depoimento da mãe do réu, ouvida como informante: JURACI MARTINS NEVES (ouvida como informante): Sou mãe do ADRIANO. Não estava na minha residência no dia do fato. Estava trabalhando. Não costumo deixar o portão da minha casa aberto; nunca deixei. O quarto do ADRIANO não é muito próximo ao portão. Dá uns 2 metros de distância do portão. [destaque meu]

Finalmente, o réu foi interrogado:

A droga era tudo para o meu uso. O rolo de fita que tinha lá estava vazio, e não tinha estilete na cama. Eu estava dormindo no momento em que os policiais chegaram. A droga era minha. Eu tinha mais ou menos 1,3 kg de maconha. Era um pé grande que eu tinha achado na beira do rio, e levei para a casa. Era um pé de maconha. Encontrei esse pé de maconha inteiro. Eu quebrei o galho desse pé e coloquei as folhas em um saco plástico, dormi e não mexi mais com nada. O meu portão estava fechado. Essas folhas embaladas eram para o uso posterior. Eram minhas mesmo. Pois bem.

Conforme se observa, os policiais civis confirmaram que realmente foram até a casa do réu previamente munidos de uma notícia anônima de que ele e outros indivíduos estariam a comercializar drogas no local. Assim, observando que o portão da casa estaria aberto, teriam adentrado o imóvel, sentindo, então, odor de maconha, motivo pelo qual se introduziram no quarto onde fizeram a apreensão da planta, folhas e frutos e autuaram o réu em flagrante.

No entanto, é evidente a ilegalidade da ação dos policiais civis.

Prescreve o art. 5º, XI, da Constituição da República:

Art. 5º. Omissis.

[...]

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; [...].

O art. 244 do Código de Processo Penal reitera tal premissa.

Note-se que a inviolabilidade somente é quebrada em caso de flagrante delito, para evitar um desastre ou por determinação judicial, esta durante o dia.

Dito isso, em primeiro lugar, não há nem sequer certeza de que o portão estivesse aberto de forma convidativa a que qualquer um transeunte pudesse entrar, tal como se tratasse a casa do réu de um local público, ou que o consentimento do morador estaria presumido.

O PC JOSÉ AUGUSTO em determinado ponto do seu depoimento aduz ter aberto o portão, o que indica que estava apenas no trinco, sem passar a lingueta à chave. Em outras palavras, o portão estava, pelo visto, fechado, mas sem a tranca.

Outrossim, conforme se verifica da fotografia de fl. 180, o portão da casa do réu é opaco, sendo impossível observar qualquer movimentação no interior do imóvel que indicasse que ele estivesse a fracionar drogas.

De todo modo, ainda que o portão estivesse apenas encostado ou entreaberto, tampouco foi o caso de o réu escancaradamente estar a fracionar drogas para quem quisesse ver, caracterizando eminentemente o flagrante, já que os policiais aduziram que somente viram tal fato ao se introduzirem no quarto do réu. Isto é, tiveram de passar pelo portão, andar alguns metros e, assim, observar o réu dentro do quarto com a planta de cannabis sativa. Tudo isso munidos apenas de uma denúncia anônima, sem qualquer outra diligência realizada ou campana ou algo que os valham, a fim de denotar que realmente havia um crime permanente ali cometido; e do fato de o réu ser conhecido nos meios policiais.

Nessa linha, consigna AURY LOPES JÚNIOR:

[...] é precisa a lição de MORAIS DA ROSA de que, "de fato, o art. 303 do CPP autoriza a prisão em flagrante nos crimes permanentes enquanto não cessada a permanência. Entretanto, a permanência deve ser anterior à violação de direitos. Dito diretamente: deve ser posta e não pressuposta/imaginada. Não basta, por exemplo, que o agente estatal afirme ter recebido uma ligação anônima, sem quem indique quem fez a denúncia, nem mesmo o número de telefone, dizendo que havia chegado droga, na casa "x", bem como que "acharam" que havia droga porque era um traficante conhecido, muito menos que pelo comportamento do agente "parecia" que havia droga. É preciso que o flagrante seja visualizado ex ante. Inexiste flagrante permanente imaginado. Assim é que a atuação policial será abusiva e inconstitucional, por violação do domicílio do agente, quando movida pelo imaginário, mesmo confirmado posteriormente. A materialidade estará contaminada pela árvore dos frutos envenenados".

O referido autor cita como precedente o Recurso Extraordinário nº 603.616, em repercussão geral (Tema 280), em que o Supremo Tribunal Federal solidificou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No mesmo sentido, veja-se o C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexiste justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida.

4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 512.418/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe de 03/12/2019)

Poderiam os agentes policiais perfeitamente terem investido em maiores investigações, inclusive durante a própria instrução processual, com possibilidade de infiltração de agentes ou de não-autuação sobre eventuais compradores usuários para ser possível a identificação do fornecedor, tudo na forma do art. 53 da Lei 11.343/2006. A propósito, o E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Sentença

condenatória. Irresignação do réu e do Ministério Público. Preliminarmente. Prova ilícita. Art. 157, CPP. Violação de domicílio. Busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem prévia justa causa. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais na casa do investigado. Delito de tráfico de drogas, ademais, que nem sempre traduz verdadeira urgência a justificar o ingresso sem autorização em domicílio alheio. Inteligência do art. 53, II, da Lei 11.343/06. Versão das testemunhas policiais frontalmente contrariada pelas demais provas (testemunhal e pericial) dispostas no processo. Alegação dos policiais de justa causa contrariada por testemunha de defesa, pela prova documental e pericial. Alegação dos policiais de que a entrada foi franqueada pelo réu contrariada pelos vídeos e perícia que mostram fortes indícios de arrombamento. Necessidade de respeito às garantias constitucionais, sob pena de esvaziamento do direito à inviolabilidade de domicílio. Ocorrência que, ademais, foi maculada por violência policial. Laudo de exame de corpo de delito que constatou ofensa à integridade corporal do réu, sendo que as lesões são compatíveis com as agressões relatadas por ele. Mérito. Reconhecida a ilicitude da prova, de rigor a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Prova testemunha colhida em juízo que é insuficiente para condenação. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso defensivo provido, prejudicado o recurso da acusação. (TJSP; Apelação Criminal 1508553-25.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Acrescente-se que não houve qualquer alegação dos policiais ouvidos de terem eles próprios visto algum ato de mercancia ou visto alguma movimentação estranha. Tudo foi embasado em denúncias anônimas e nos antecedentes do réu, motivo pelo qual a prova obtida é ilícita, com fulcro no art. 5º, LVI, da Constituição e do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos, tornando, conseqüentemente, nulo o flagrante.

E, excluindo-se a apreensão, não há nada nos autos que incrimine o réu, sendo imperiosa sua absolvição, ficando prejudicada a análise do pedido subsidiário da Defesa para desclassificação para posse para uso pessoal.

Non liquet de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para ABSOLVER o réu ADRIANO MARTINS NEVES do crime que lhe é imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO RÉU.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo nomeado em favor do réu pelo Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lencois Paulista, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA